

NOTAS SOBRE KIRCHNERISMO Y JUSTICIA

Roberto Gargarella

El objetivo general de este capítulo es realizar un examen sobre la relación entre kirchnerismo y justicia. Dadas las limitaciones de espacio y mi interés por hacer uso del mismo del mejor modo, dejaré de lado una alternativa posible pero poco interesante en este marco, como la de realizar un repaso descriptivo de los hechos notables o puntos destacados de esta relación entre kirchnerismo y justicia. Por ello, este capítulo se concentra sólo en dos hechos relevantes de este fenómeno que pueden ayudar a mirar más allá de la justicia, y a pensar en la lógica, o en ciertos parámetros importantes, que han marcado la vida pública en los últimos tiempos.

Se abordan así dos aspectos de la compleja y difícil relación entre el kirchnerismo y la justicia, englobando bajo la idea de “justicia” a los asuntos relacionados con la actuación del poder judicial. En primer lugar, se examinarán los cambios introducidos, al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, en la composición de la Corte Suprema; y en segundo lugar, el capítulo se detendrá en la reforma del Consejo de la Magistratura producida en 2006.

La preferencia por estas dos cuestiones obedece a varias razones, entre las que se destacan las siguientes. En primer lugar, la selección de este par de hechos obedece a su valor objetivo: se trata de dos cambios sustantivos, ineludibles cada vez que se quiera pensar en lo actuado por el poder político sobre la justicia, durante los primeros años del kirchnerismo en el poder (2003-2011). En segundo término, la importancia de ambos acontecimientos trasciende largamente a los

mismos ya que –como se verá– ellos remiten a políticas de fondo, antes que a decisiones coyunturales tomadas de modo intempestivo por el poder ejecutivo. Finalmente, tales actos destacan por la aparente contradicción que insinúan. Por un lado, la reforma en la composición de la Corte sugiere una vocación de auto-limitación por parte del ejecutivo –un intento de atarse las manos a sí mismo, con el objeto de asegurar la mayor independencia de los poderes encargados de controlarlo. En cambio, y por otro lado, la reforma a la ley que organiza al Consejo de la Magistratura sugiere una vocación de control sobre la justicia, por parte de la presidencia. Es difícil no quedar perplejo, entonces, frente al hecho de que sólo luego de tres años de la reforma en la composición de la Corte, el poder ejecutivo haya dado un giro tan drástico en su política frente a la justicia. En las páginas que siguen, se intentará, a partir de los dos hechos citados, explicar este giro y, al mismo tiempo, realizar una reflexión más general sobre la relación entre kirchnerismo y justicia.

1. Cambiar la composición de la Corte

A través del ya famoso decreto 222/03, Néstor Kirchner impulsó la designación de nuevos magistrados en la Corte Suprema, un hecho que vino de la mano de diferentes iniciativas promovidas desde el Ejecutivo, y orientadas a remover a algunos de los más cuestionados miembros del tribunal. El decreto estableció un mecanismo novedoso para la renovación de los jueces, que incluyó una clara preocupación por la transparencia y la publicidad de los procedimientos, y también la decisión de asegurar una mayor diversidad de género, enfoques y proveniencia geográfica, entre los integrantes del tribunal.¹ Junto con estas medidas destinadas a provocar cambios en la composición del máximo organismo judicial, cabría destacar dos cuestiones adicionales. Primero, el resultado de los cambios: indudablemente, la integración de la Corte luego de los nombramientos realizados por el kirchnerismo resultó muchísimo más atractiva que la que existiera hasta entonces.² Al respecto, cabe recordar que poco tiempo atrás, la Corte se había

1. El decreto 222/03 establece en su artículo 3º: “Dispónese que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

2. En 2003 fue designado Eugenio Raúl Zaffaroni. Y en 2004 se sumaron Elena Highton de Nolasco y Carmen María Argibay, convirtiéndose en las dos primeras mujeres en la Corte Suprema nombradas por un gobierno democrático. En 2005, el Congreso nacional destituyó

visto casi diariamente acosada por insólitas, inéditas manifestaciones en la puerta de los tribunales (sino en la puerta misma de los domicilios de sus integrantes), en razón del descomunal desprestigio que rodeaba a muchos de sus miembros (acusados de corrupción, sometimiento al poder político, impericia, indecencia, etc.). Segundo, es para destacar que tales reformas se dieron en el comienzo mismo del mandato de Néstor Kirchner, y quedaron por tanto inscriptas en la etapa más liberal-republicana de su gobierno. Hoy, todavía, luego de casi dos mandatos completos, se sigue esgrimiendo a los cambios en la Corte —aquellos producidos en el minuto uno del kirchnerismo— como “carta ganadora”, frente a quienes acusan al gobierno por sus prácticas contra-institucionales, o por su desdén institucional.

Hay muchas maneras de pensar lo ocurrido, pero en estas líneas exploraré una en especial que, para algunos, quizá no resulte la más común ni, tal vez, la más pertinente. Los cambios en la composición de la Corte pueden leerse como la mejor expresión, durante el kirchnerismo, de una lógica política habitual en la historia argentina. Esta “lógica” tendría la siguiente forma. Luego de una etapa de retracción autoritaria o conservadora, la política argentina tiende a abrir espacio a iniciativas más liberales, que concitan atracción y respaldo popular, en un principio, pero que se terminan cerrando, más o menos prontamente, a partir de la amenaza de los grupos más conservadores (llámese ésta, en distintos momentos históricos, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los intendentes “barones” o “dueños” del conurbano bonaerense; el “aparato” del Partido Justicialista, etc.). La certeza que mueve a los políticos (en apariencia, más) liberal-republicanos es la de que el respaldo popular es efímero, y que la apuesta por la estabilidad no puede fundarse en dicho consenso —tan aparentemente volátil—, sino que requiere el apoyo en las “fuerzas del poder real”, que no pueden ser finalmente marginadas del ejercicio del poder político.

Dentro del período kirchnerista, la modificación de la Corte Suprema representa el primer, gran, decisivo paso “liberal” de un gobierno abiertamente orientado a dejar atrás una larga etapa de retracción conservadora. Este primer gran paso es consistente con otras acciones del gobierno, y también con su discurso político insistente, el que marca a toda esta etapa. El kirchnerismo propone e intenta reordenar las cuentas públicas, renegociar la deuda externa, atarse las manos frente a la protesta social, reivindicar las alianzas “cruzadas” o “transversalidad” política, embestir —retóricamente al menos— contra el “aparato” peronista y los viejos caudillos y líderes políticos locales acusados de corrupción y clientelismo.

a Antonio Boggiano, mientras que Augusto Belluscio renunció. Las dos vacantes no fueron nunca cubiertas por el gobierno.

La política “liberal” del kirchnerismo fue en extremo exitosa, al menos si uno toma como parámetro las encuestas de popularidad ampliamente favorables en aquellas primeras semanas de gobierno. Sin embargo, al poco tiempo, el presidente Kirchner se vio enfrentado al mismo dilema que siempre, históricamente, ha atormentado al liberalismo local, desde el momento mismo de la Independencia: radicalizar la apuesta ciudadana, retomando la agenda cívica, y apoyándose en derechos políticos expandidos, anti-corporativa; o rechazar dicha alternativa, como incapaz de dotar al gobierno de la estabilidad y solidez necesarias, para abrazar en su lugar una alianza más tradicional, con los grupos –conservadores– más establecidos. Kirchner decidió rápidamente, bastante más pronto aún que muchos otros presidentes democráticos que lo precedieron, como Arturo Frondizi o Raúl Alfonsín, que la única alternativa sería para mantenerse en el poder era la de apoyarse en el “viejo aparato” político, que él mismo se había encargado de repudiar con dureza en sus primeros días de gobierno.

Este giro anti-liberal, conservador, del gobierno de Kirchner encontrará obvia correlación en su vínculo cada vez más tenso con la justicia en general, y también, particularmente, con la Corte, que había sido objeto de su cuidadosa atención en los inicios del mandato. Un importante ejemplo sobre lo primero se verá en breve, con las modificaciones que el kirchnerismo introduce en el Consejo de la Magistratura. Antes, cabe señalar los reiterados casos en que el oficialismo se negó a aceptar o poner en práctica decisiones de la Corte Suprema que consideró desfavorables a su propio programa de gobierno. Así, y sólo por citar algunos ejemplos muy salientes, podría mencionarse la negativa del kirchnerismo a reponer al procurador de Santa Cruz, Eduardo Emilio Sosa, indebidamente removido de su cargo por el partido en el gobierno. De modo similar, el kirchnerismo se mostró absolutamente renuente a acatar otro fallo del máximo tribunal, en donde este último defendió la libertad de agremiación de los trabajadores y declaró inconstitucional la exclusividad que tienen los sindicatos con personería gremial en la representación de sus afiliados. Asimismo, luego del fallo “Perfil”, el gobierno directamente ridiculizó a la Corte, en lugar de cumplir con las órdenes recibidas de parte de ésta. Recuérdese que a través de este fallo la justicia condenó en fuertes términos la política discrecional llevada a cabo por el gobierno en materia de distribución de las pautas oficiales para la publicidad. El gobierno, asimismo, resistió el cumplimiento de obligaciones ordenadas por la Corte en lo relativo al pago de las jubilaciones; y se mostró renuente a llevar a cabo su parte, luego de la decisión del caso “Mendoza”, referido a la contaminación del Riachuelo. Es decir, en las áreas más diversas –democracia sindical, medio ambiente, libertad de expresión, política provisional, división de poderes, etc.– el gobierno desobedeció directamente a lo que la Corte le ordenara.

Notablemente, hoy se presencia del modo más crudo esta doble actitud del gobierno que, por un lado, sigue reivindicando como el primer día la reno-

vacación de la Corte (un acto que es presentado, con razón, como símbolo de su preocupación por el buen funcionamiento del sistema de “frenos y contrapesos”), a la vez que, por otro lado, desacata las órdenes del máximo tribunal, sistemáticamente, cuando éstas interfieren con sus pretensiones, aún las más modestas (ofendiendo así, de modo gravísimo, al sistema de “frenos y contrapesos” que proclamaba honrar).

En todo caso, en lugar de concentrar la atención en señalar las contradicciones incurridas por un gobierno poco interesado en la consistencia de sus actos, el interés de este capítulo es el de mostrar otra cosa, esto es, una lógica política que puede ayudar a entender ese actuar en apariencia contradictorio. La lógica señalada torna inteligible, primero, la delicadeza con que el gobierno se aproximó a la Corte, en sus comienzos, y luego, la brutal crudeza con que se desentendió de los fallos adversos de aquella. En mi opinión, esta mirada sobre la cuestión resulta más rica que otras alternativas, que se dirigen a ensalzar al gobierno por lo primero (renovación de la Corte), ocultando lo segundo (la desobediencia); o viceversa.

2. La reforma del Consejo de la Magistratura

La Constitución de 1994 creó la institución del Consejo de la Magistratura, según algunos, la reforma más importante implementada por los convencionales en el ámbito de la justicia. Nunca he sido un entusiasta de la creación del Consejo, aunque puedo entender la preocupación por garantizar mayor independencia a la justicia, sobre todo en lo relativo a la designación y remoción de jueces. La principal objeción era –y sigue siendo– que el Consejo sólo llevaba a un estadio superior los problemas que rodeaban a la designación y remoción de jueces en el “viejo sistema”. En todo caso, una vez creada la nueva institución, la pregunta pasó a ser otra: ¿cómo garantizar su mejor funcionamiento?

En tal sentido, el kirchnerismo dio un paso muy serio y muy cuestionable: la ley 26.080. A través de esta norma, modificó la composición del organismo –que ya había sido fijada por una ley especial, que establecía, por caso, una composición de 20 miembros, “equilibrada”. La primera ley relativa al Consejo de la Magistratura procuraba seguir al artículo 114 de la Constitución nacional y su mandato de “equilibrio” en la composición del cuerpo. En efecto, y según el texto de la Constitución, el Consejo debía procurar el “equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.

Contra lo establecido por la norma originaria, la nueva ley 26.080 promovida por el kirchnerismo, en tiempos de mayorías favorables en el Congreso nacional (lo cual ofrece un buen “test” sobre los modos en que el gobierno usa al poder), distorsionó

de modo significativo el “equilibrio” constitucional exigido, reduciendo de veinte (20) a trece (13) los miembros del Consejo, y aumentando, en los hechos, a cinco (5) los representantes del partido oficialista en dicho organismo. Peor aún, la reforma del caso fue aprobada sin abrir ningún proceso de discusión seria con la oposición en el Congreso (bastardeando, más bien, dicha discusión), bajo la “orden” dada por el presidente Kirchner de aprobar el proyecto del oficialismo “sin cambiar una coma” del mismo.

Otra vez, son muchas las cosas que pueden decirse sobre el tema —aquí, para objetar dicha ley, y así también a la actitud de un gobierno que, a través de tal acción, sorprendería a tantos. ¿Cómo puede ser —se preguntaban muchos— que el mismo gobierno que se preocupa por la independencia de la Corte, modifique de este modo al Consejo de la Magistratura —garantía de la independencia judicial— de forma tal de ganar control sobre el mismo? Aquí se ha ensayado ya alguna respuesta capaz de explicar por qué la acción del gobierno no era sorprendente. Queda centrarse, por ello también, en otra cuestión, que vuelve a poner un hecho específico, relacionado con el vínculo gobierno-poder judicial (en este caso, la modificación del Consejo de la Magistratura) dentro de un marco teórico mayor: el modo en que la reforma del Consejo da pistas firmes acerca de la concepción de democracia que anida en el kirchnerismo.

Por supuesto, muchos podrán decir que esta pretensión de examinar la concepción de la democracia con la que aparece comprometido el kirchnerismo es “ir demasiado lejos”, cuando de lo que se trata es de examinar el mero actuar de un gobierno —éste o cualquiera— que busca afirmarse en el poder. Sin embargo, esta réplica no resulta demasiado interesante, y para ello basta con hacer un breve recorrido por la historia argentina o latinoamericana. Afectados por crisis económicas y políticas similares, algunos gobiernos latinoamericanos se han mostrado más inclinados a resolver los dilemas que enfrentan a través de salidas más democráticas (la apuesta plebiscitaria en Uruguay); otros han abrazado concepciones muy severas de lo que podría llamarse el positivismo jurídico (piénsese en Chile, y en el peso que ha tenido allí, en democracia, el legado jurídico del “pinchetismo”); otros han mostrado una duplicidad tal que los ha llevado a avalar, al mismo tiempo, la comisión de actos atroces, y el estricto respeto a la legalidad (tómese a Colombia y las avanzadas decisiones de su Corte Constitucional, en el contexto de una práctica política de violencia extrema). Aquí se presentan estas simplistas generalizaciones sólo para decir que “no todo es lo mismo”, que la “ambición desmedida de poder” que queremos atribuirle a todo gobierno, a todos los gobernantes, encuentra finalmente manifestaciones muy diferentes, y que tiene sentido reconocer, distinguir y pensar esas diferencias.

En la modificación del Consejo de la Magistratura, tanto como en otras medidas de crucial importancia, como la llamada “Ley de Superpoderes” o el mismo decreto —antes que ley— destinado a crear la Asignación Universal por

Hijo, el gobierno de los Kirchner mostró una actitud muy clara en relación con valores democráticos fundamentales. No le interesó escuchar argumentos contrarios a su posición; no se preocupó por refutar a quienes pensaban distinto; no le importó justificar su actitud frente a quienes mostraban ideas contrarias a las oficiales; no se enteveró en un debate franco con la oposición; no le interesó aprender de ella; no se abrió a cambiar de posición, no aceptó correcciones a su postura. Por el contrario, radicalizó su posición inicial, se mostró indispuerto a concordar con la oposición, al punto que –en la ley en cuestión, sobre el Consejo de la Magistratura– simplemente cumplió a rajatabla con la orden presidencial –inconstitucional, anti-democrática– de “no cambiar una coma” del proyecto original. En otras ocasiones, y ante dilemas similares, el gobierno impondría secamente su mayoría en el Congreso; haría lo que se había propuesto hacer sin atender en absoluto las importantes objeciones de la oposición; o, desde que perdiera las mayorías cómodas que lo beneficiaban en el Congreso, saltaría directamente al legislativo, para imponer sus decisiones por medio de –en su mayoría inconstitucionales– decretos de necesidad y urgencia. No se trató, en estos casos, simplemente, de innecesarios, indebidos, desaconsejables “castigos” a la oposición. La respuesta jurídica del gobierno fue mucho más allá de un “mero” castigo a los opositores. Al privar de apoyo amplio a ciertas medidas –en particular, en la importante medida de la Asignación por Hijo–, al impedir que las mismas gozaran de todo el respaldo y fuerza propias de una ley, golpeó gravemente a la autoridad y estabilidad de tales decisiones que, por su entidad, necesitaban muy especialmente del respaldo del Congreso nacional.

Como en el caso del cambio en la composición de la Corte, la modificación de la integración del Consejo de la Magistratura ayuda a entender la relación entre el gobierno y la justicia; pero también, otros actos de los Kirchner, en su vínculo con organismos públicos y privados, políticos o no. Por supuesto, se puede intentar una explicación de lo hecho por el gobierno, en materia judicial o en otras, de muchas maneras. Sin embargo, aquí se subraya la importancia de no olvidarse de esta dimensión –la dimensión democrática– que no sólo puede enriquecer las explicaciones sobre lo que hizo, hace y deja de hacer el gobierno de los Kirchner, sino que también ayuda a pensar en torno a lo que podría y debería hacer, si estuviera animado por otro tipo de ideales democráticos, más robustos y bien alejados de una concepción elitista de la propia democracia.

3. Algunas conclusiones

En este breve capítulo se ha buscado poner de relieve dos cuestiones. En primer lugar, remarcar el carácter efímero que suelen tener las iniciativas de tipo liberal en nuestro país, un país marcado por la desigualdad y la injusticia social; y la sobre-presencia que adquieren las fuerzas del (injusto) orden establecido, como las únicas capaces de proveer estabilidad política a un escenario caracterizado por su fuerte inestabilidad (inestabilidad que en algún momento, pero no ahora, se manifestaba, fundamentalmente, a través de golpes de Estado). En segundo término, el análisis formulado sugiere algunos de los rasgos definitorios de la inatractiva, estrecha, limitada visión de la democracia con la que aparece vinculado el kirchnerismo (y, más en general, varios otros gobiernos democráticos que han ejercido el poder en la Argentina). Ambas cuestiones, claramente, no parecen separadas entre sí. En cierto modo, el partir de una visión tan empobrecida de la democracia –una que exhibe una gran desconfianza en torno al protagonismo posible de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas– hace inteligible el marco de alianzas que el gobierno de los Kirchner –como otros previos– ha tendido a impulsar. En lugar de abrirse a la ciudadanía, tratando de apoyarse en el respaldo ciudadano, el oficialismo ha preferido confiar su estabilidad a los poderes establecidos más tradicionales (en este caso, el poder del “aparato” peyotista que el mismo kirchnerismo denunciara; o en la estructura más burocratizada, corrupta y criminal, dentro del sindicalismo). Su desconfianza democrática, en definitiva, explica su decisión de pactar con quien previamente sindicara como enemigo, su decisión de concentrar más poder sobre sí mismo y también, finalmente, su creciente –y para algunos inesperado– enfrentamiento con la administración de justicia.

Lecturas adicionales

Como respaldo para los fallos citados, se sugiere leer los libros anuales publicados, con resúmenes y comentarios de fallos, por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), *La Corte Suprema y los derechos*, y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), *Derechos Humanos en la Argentina*.